

Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 14Co/371/2012
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6712203774
Dátum vydania rozhodnutia: 03. 09. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Priehoda
ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6712203774.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Priehodu a členov senátu JUDr. Márie Podhorovej a Mgr. Emy Novodomcovej, v právnej veci navrhovateľa : Orange Slovensko, a.s., so sídlom 821 09 Bratislava, Prievozská 6/A, IČO : 35 697 270, zastúpený splnomocnenou Advokátskou kanceláriou URBÁNI & Partners, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 17, IČO : 36 656 181, proti odporcovi : Q. V., narodený XX.XX.XXXX, bytom XXX XX S., Q. Y. XX, zastúpený splnomocnenou advokátkou Mgr. Katarínou Milanskou, so sídlom Advokátska kancelária 960 01 Zvolen, J. Kozačeka 146/13, o zaplatenie 873,55 eur s príslušenstvom, o odvolaní odporcu zo dňa 13.08.2012 proti rozsudku Okresného súdu Zvolen číslo konania 10C/33/2012-81 zo dňa 25.06.2012, takto

rozhodol:

Rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 549,46 eur spolu s 8,5 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 549,46 eur od 26.06.2008 do zaplatenia a nahradiť navrhovateľovi trovy konania **p o t v r d z u j e**.

Vo zvyšnej časti zostáva rozsudok okresného súdu nedotknutý.

Odporca **j e p o v i n n ý** nahradiť navrhovateľovi trovy odvolacieho konania v sume 70,90 eur, pozostávajúce z trov právneho zastúpenia, na účet splnomocneného právneho zástupcu navrhovateľa č. ú.: XXXXXXXXXXX/XXXX, v lehote do troch dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 549,46 eur spolu s 8,5 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 549,46 eur od 26.06.2008 do zaplatenia, v prevyšujúcej časti súd návrh zamietol a rozhodol o náhrade trov konania, keď uložil odporcovi povinnosť nahradiť navrhovateľovi trovy konania spočívajúce v pomernej časti súdneho poplatku za návrh vo výške 13,52 eur a trovách právneho zastúpenia v sume 60,89 eur. Súd právne posúdil záväzkový vzťah účastníkov konania zo Zmluvy o pripojení č.U. zo dňa 27.10.2006 v znení Dodatku k zmluve zo dňa 27.10.2006 ako obchodnoprávny vzťah a aplikoval na daný zmluvný vzťah ustanovenia zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, v spojení s ustanoveniami § 301 a § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. Súd sa nestotožnil s obranou odporcu, že v danom záväzkovom vzťahu mal postavenie spotrebiteľa, nakoľko mal v konaní preukázané, že tak pri uzatváraní predmetnej zmluvy, ako aj pri jej plnení, konal odporca v rámci svojej podnikateľskej činnosti, keďže sám odporca výslovne uviedol, že predmetný mobilný telefón používal aj v rámci svojho podnikania a aj v zmluve o pripojení bol odporca označený ak fyzická osoba- podnikateľ s uvedením obchodného mena, miesta podnikania a IČO. Následne súd skúmal oprávnenosť uplatneného nároku v pôvodnej sume 873,55 eur a konštatoval, že odporca nezaplatil navrhovateľovi cenu za poskytnuté elektronické telekomunikačné služby v sume 149,46 eur (po zohľadnení čiastočného späťvzatia návrhu ohľadom faktúry vystavenej na sumu 60,21

eur). Spornou zostala navrhovateľom uplatnená zmluvná pokuta pôvodne v sume 663,88 eur, ktorej výšku súd považoval za neprimerane vysokú a preto využil svoje moderačné oprávnenie vyplývajúce z ustanovenia § 301 Obchodného zákonníka a vychádzajúc z výšky škody spôsobenej navrhovateľovi porušením zmluvnej povinnosti zo strany odporcu považoval za primeranú zmluvnú pokutu vo výške 400 eur. Pri rozhodovaní o primeranosti výšky zmluvnej pokuty súd vychádzal z predajnej ceny mobilného telefónu v sume 464 eur, od ktorej odpočítal sumu 164 eur, ktorú za mobilný telefón odporca navrhovateľovi uhradil, čo predstavovalo rozdiel 300 eur. Následne súd zohľadnil aj výšku škody, ktorá navrhovateľovi vznikla v dôsledku nesplnenia si povinnosti odporcom zotrvať v zmluvnom vzťahu po stanovenú dobu viazanosti a mať aktivovaný účastnícky program, u ktorého výška mesačného poplatku bez DPH bola stanovená na sumu najmenej 16,56 eur mesačne. Doba viazanosti bola dohodnutá na 24 mesiacov, za toto obdobie by bol odporca povinný minimálne zaplatiť navrhovateľovi formou mesačného poplatku sumu 397,44 eur, následne potom súd znížil túto sumu pomerne k počtu mesiacov, ktoré zostávali do skončenia doby viazanosti a takouto úvahou súd určil čiastku 100 eur, ktorá spolu s rozdielom medzi predajnou cenou mobilného telefónu a reálne zaplateniu kúpnu cenou mobilného telefónu, teda sumou 300 eur, predstavujú výšku škody, ktorá vznikla navrhovateľovi porušením povinnosti zo strany odporcu, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Spolu tak súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi ako oprávnený nárok sumu 149,46 eur ako vyúčtované služby za poskytnutie elektronických telekomunikačných služieb spolu s modifikovanou výškou zmluvnej pokuty v sume 400 eur, spolu tak zaplatiť sumu 549,46 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,5% ročne z tejto sumy odo dňa omeškania 26.06.2008 do zaplatenia. O náhrade trov prvostupňového konania súd rozhodol s poukazom na ustanovenie § 142 ods. 2 O.s.p., a po konštatovaní čiastočného procesného úspechu navrhovateľa mu súd priznal náhradu trov konania spočívajúcich v časti zaplateného súdneho poplatku za návrh a v trovách právneho zastúpenia, spolu náhradu trov konania v sume 74,41 eur, ktoré uložil odporcovi zaplatiť na účet splnomocneného právneho zástupcu navrhovateľa s poukazom na ustanovenie § 149 ods. 1 O.s.p., v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti rozsudku okresného súdu vo výroku, ktorým súd návrhu vyhovel, podal odporca v zákonom stanovenej lehote odvolanie, nakoľko sa domnieva, že došlo k nesprávnemu právnomu posúdeniu veci. V prvom rade odporca zotrváva na pôvodne prezentovanom stanovisku, že Zmluvu o pripojení č. U. uzavretú podľa zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a jej Dodatok zo dňa 27.10.2006 je nutné považovať v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka za spotrebiteľskú zmluvu. Odporca síce ako účastník zmluvy vystupoval ako fyzická osoba - podnikateľ, to však neznamená, že mu nemôže byť poskytnutá ochrana v rámci spotrebiteľských zmlúv, pokiaľ jednal mimo obchodných aktivít. Odporca konal v záujme uspokojenia svojich vlastných - osobných potrieb, prípadne rodinných potrieb, pretože mobilný telefón užíval na súkromné účely. Pokiaľ ide o súdom modifikovanú výšku zmluvnej pokuty, odporca uviedol, že počas doby viazanosti v trvaní 24 mesiacov bol v omeškaní s úhradou ceny služieb za mesiace február, marec a apríl 2008 a spolu nedoplatok na cenách poskytnutých služieb predstavoval sumu 209,67 eur. Odporca riadne uhradil 21 x 16,56 eur, teda sumu 347,76 eur, ako sumu mesačných poplatkov za služby navrhovateľa. Odporca potom zhrnul, že počas trvania zmluvného vzťahu s navrhovateľom z dohodnutej sumy 397,44 eur uhradil navrhovateľovi sumu 347,76 eur, ako aj sumu 164 eur ako kúpnu cenu telefónu, čo predstavuje potom oproti zmluvne dohodnutej sume celkový rozdiel vo výške 49,68 eur, ako prípadná škoda na strane navrhovateľa. Navyše, podľa odporcu navrhovateľ v konaní ani netvrdil, že by mu vznikla škoda, navrhovateľ výšku tejto škody ani neurčil a voči odporcovi si ju ani neuplatnil, pričom súd nesprávne pasivitou navrhovateľa v konaní nahradil postupom podľa ustanovenia § 136 O.s.p., čím súd podľa názoru odporcu porušil prejednávaciú zásadu, ktorou sa spravuje konanie na súde. Súčasne sa odporca domnieva, že takto súdom vypočítaná škoda vzniknutá navrhovateľovi nie je objektívna a považuje ju za neprimerane vysokú. Navrhuje preto, aby odvolací súd zrušil rozsudok okresného súdu, nanovo rozhodol a uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 49,67 eur s úrokom z omeškania vo výške 8,5% ročne zo sumy 49,68 eur od 26.06.2008 do zaplatenia a súčasne si uplatnil a vyčísľil aj trovy odvolacieho konania.

Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu odporcu uviedol, že nesúhlasí s tvrdením odporcu ohľadom skutočnosti, že Zmluvu o pripojení a dodatok k nej treba posudzovať ako zmluvu spotrebiteľskú. Odporca pri uzatváraní Zmluvy o pripojení č. U. zo dňa 27.10.2006, ako aj Dodatku k danej zmluve vystupoval ak fyzická osoba- podnikateľ s označením obchodným menom a miestom podnikania a poskytované služby využíval v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Definícia spotrebiteľa podľa ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka vymedzuje status spotrebiteľa jedine na fyzické osoby. Navrhovateľ v tejto súvislosti poukázal a citoval z viacerých rozhodnutí všeobecných súdov. Navrhovateľ preto navrhuje,

aby odvolací súd rozsudok okresného súdu ako vecne správny potvrdil a súčasne si vyčíslil a uplatnil aj trovy odvolacieho konania.

V dôsledku odvolania krajský súd, ako súd odvolací, vec preskúmal v medziach daných ustanovením § 212 ods. 1 O.s.p. a bez nariadenia pojednávania v súlade s ustanovením § 214 ods. 2 O.s.p. rozsudok v odvolaní napadnutom výroku a v súvisiacom výroku o trovách konania podľa ustanovenia § 219 ods. 1 a 2 O.s.p. ako vecne správny potvrdil.

Okresný súd vykonal dokazovanie vo veci jednak výsluchom účastníkov konania a oboznámením sa s obsahom predložených a vyžiadaných listinných dôkazov a po ich dôkladnom zvážení a vyhodnotení následne na podklade takto zisteného skutkového stavu zaujal právne stanovisko obsiahnuté v rozsudku, ktorým meritorne vo veci rozhodol. Je potrebné zdôrazniť, že odporca, ako odvolateľ, neuviedol v odvolaní žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe súdu prvého stupňa, ani nežiadal doplniť dokazovanie za podmienok stanovených v ustanovení § 213 ods. 4 a 5 O.s.p. o ďalšie nové relevantné skutočnosti, ktoré nemohli byť prezentované v prvostupňovom konaní. Odvolaním len spochybnil vyodený právny názor súdu prvého stupňa na podklade vykonaného dokazovania. Odvolací súd preskúmal odvolaním napadnutý rozsudok prvostupňového súdu v rozsahu podaného odvolania a aplikujúc ustanovenie § 219 ods. 2 O.s.p. sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku a konštatuje správnosť dôvodov a právnych úvah na podklade ktorých prvostupňový súd rozhodol.

V konaní nebol sporný právny základ, z ktorého uplatnený nárok vzišiel, a to skutočnosť, že medzi navrhovateľom, ako poskytovateľom elektronických telekomunikačných služieb a odporcom, ako účastníkom telekomunikačnej siete, bola uzatvorená Zmluva o pripojení č. U. zo dňa 27.10.2006 a Dodatok k Zmluve o pripojení zo dňa 27.10.2006 podľa § 43 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, na základe ktorých sa navrhovateľ zaviazal poskytovať odporcovi elektronické telekomunikačné služby v dojednanom rozsahu a za stanovených podmienok v rozsahu odporcom zvoleného účastníckeho paušálu 90+SMS a osobitných služieb Orange World Mini, CLIP a predatť odporcovi, ako účastníkovi telekomunikačnej siete koncové telekomunikačné zariadenie - mobilný telefón typu Siemens EF81 za akciovú sumu 164 eur. Odporca sa zaviazal platiť navrhovateľovi mesačné platby za zvolený účastnícky program - Paušál 90+SMS a platby za ďalšie poskytnuté služby telekomunikačného operátora a zotrvať v zmluvnom vzťahu s navrhovateľom počas doby viazanosti - 24 mesiacov.

Pokiaľ odporca namietal predovšetkým nesprávne právne posúdenie veci, pretože súd prvého stupňa na daný skutkový stav neaplikoval ustanovenia na ochranu spotrebiteľa, odvolací súd, vychádzajúc z obsahu spisu, poznamenáva, že obrana odporcu, na ktorej zotrváva aj v štádiu odvolacieho konania, je v rozpore so skutočnosťami vyplývajúcimi z obsahu listinných dôkazov, no v neposlednom rade je aj v priamom rozpore s vyjadreniami samotného odporcu v konaní pred súdom prvého stupňa.

Odvolací súd nespochybňuje právnu argumentáciu odporcu, že skutočnosť, že bol v zmluvnom vzťahu s navrhovateľom označený ako fyzická osoba - podnikateľ, ešte sama osebe nevylučuje právny záver, že by nemohol zmluvou o pripojení byť založený spotrebiteľský vzťah a zmluva o pripojení spolu s dodatkom k nej, nemôže byť právne kvalifikovaná ako spotrebiteľská zmluva podľa ustanovení § 52 až 54 Občianskeho zákonníka. V konkrétnej veci je však zrejmé, že na daný zmluvný vzťah založený Zmluvou o pripojení č. U. zo dňa 27.10.2006 a Dodatkom k Zmluve o pripojení zo dňa 27.10.2006 okrem ustanovení lex specialis- zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, nedopadá právna úprava podľa ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka upravujúca spotrebiteľské zmluvy. Lex generalis spotrebiteľa definuje v ustanovení § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, podľa ktorej dĺžnik spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Nakoľko však bolo preukázané, že dĺžnik - odporca je podnikateľským subjektom a v danej veci pri uzatváraní a plnení zmluvy konal v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nie je možné vzhľadom na všetky zákonné kritériá považovať daný zmluvný vzťah medzi navrhovateľom a odporcom za spotrebiteľský vzťah v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a následne potom ani podriaďiť ho právnomu režimu tejto normy upravujúcej problematiku spotrebiteľských zmlúv a spotrebiteľských vzťahov. Odvolací súd tento právny záver vyvodzuje jednak z označenia dĺžnika v zmluve o pripojení, ako aj v dodatku k tejto zmluve identifikačnými znakmi typickými pre podnikateľa - a to obchodným menom, miestom

podnikania a identifikačným číslom. Pokiaľ účastník zmluvného vzťahu mal záujem takto sa označiť v zmluve o pripojení a dodatku k nej a súčasne aj výslovne na pojednávaní konanom dňa 25.06.2012 deklaroval, že používal mobilný telefón s pridelenou SIM kartou striedavo, na súkromné ale aj na firemné účely, je zrejmé, že odporcu v právnom vzťahu vyplývajúcom z danej zmluvy o pripojení a dodatku k nej nie je možné považovať za fyzickú osobu nekonajúcu pri uzatváraní zmluvy a jej plnení v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a nie sú tak naplnené zákonné kritériá spotrebiteľskej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Z vyjadrenia odporcu na pojednávaní dňa 25.06.2012 taktiež vyplynulo, že slobodne využil možnosť označiť sa v zmluve o pripojení ako živnostník- podnikateľ a to z dôvodu, že mu z tejto skutočnosti vyplynuli výhody, o ktoré mal záujem, konkrétne zľava na ním vybraný mobilný telefón. Pre odvolací súd je navyše veľmi kontroverzné a paradoxne vyznejúce (vzhľadom na odvolacie dôvody) vyhlásenie právnej zástupkyne odporcu, prezentované na pojednávaní dňa 25.06.2012 a zažurnalizované v zápisnici z daného pojednávania, ktorá uviedla, že „skutočnosť, že odporca v čase uzavretia predmetnej zmluvy podnikal pod obchodným menom V. Q.- P. nespochybňujú a z toho dôvodu teda sa stotožňujú s názorom navrhovateľa, že predmetný vzťah je potrebné posudzovať podľa Obchodného zákonníka“ (č.l. 75 spisu). V prípade, ak účastník konania na základe slobodnej voľby koná v zmluvnom vzťahu ako podnikateľ - živnostník a takto sa preukazuje v procese uzatvárania zmluvy a za týmto účelom aj vyhlási, že poskytované služby zo zmluvy vyplývajúce mienil používať a aj reálne používal na podnikateľské účely a nielen na vlastnú spotrebu, je treba mať za to, že podmienky stanovené v hypotéze právnej normy ustanovenia § 52 OZ neboli naplnené a posudzovaný vzťah nie je vzťahom spotrebiteľským z dôvodu, že v danom prípade nič nenasvedčuje, že ide o zmluvný vzťah uzavretý so spotrebiteľom.

Odporca v konaní nespochybnil tvrdenie navrhovateľa, že nezaplatil riadne a včas vyúčtovanú sumu za poskytnuté telekomunikačné služby v sume 149,46 eur (ako zvyšnej časti fakturovaných súm po čiastočnom späťvzatí návrhu ohľadom faktúry vystavenej v sume 60,21 eur), súd prvého stupňa preto správne uložil odporcovi povinnosť zaplatiť túto čiastku, ako odporcom nespochybnený nárok navrhovateľa. V zmysle bodu 2.5 Dodatku k Zmluve o pripojení bol v prípade porušenia niektorej zo zmluvne dohodnutých povinností účastník povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 000,- Sk (663,88 eur), v ktorej sume si navrhovateľ aj zmluvnú pokutu v danom konaní uplatnil. Súd správne považoval zmluvnú pokutu uplatnenú v takejto sume za neprimerane vysokú a následne potom zmluvnú pokutu s poukazom na ustanovenie § 301 Obchodného zákonníka znížil na sumu 400 eur. Odvolací súd nepovažuje postup súdu, ktorý svojou úvahou v intenciách ustanovenia § 136 O.s.p. stanovil výšku zmluvnej pokuty s prihliadnutím na škodu spôsobenú navrhovateľovi nedodržaním zmluvných povinností zo strany odporcu, za arbitrárny a rozporný so zákonom. Úvahy odporcu, prezentované v odvolaní, že súd je oprávnený skúmať primeranosť zmluvnej pokuty len v rozsahu uplatnenej a presne špecifikovanej škody druhým účastníkom konania, nemá oporu v zákone. Ustanovenie § 301 Obchodného zákonníka umožňuje súdu neprimerane vysokú zmluvnú pokutu znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Nie je vylúčený postup, ktorý zvolil súd prvého stupňa, ktorý svojou úvahou, ktorú podrobne v odôvodnení rozsudku zdôvodnil, stanovil výšku škody na sumu 400 eur, a to vychádzajúc z rozdielu medzi predajnou cenou mobilného telefónu a zaplatenou kúpnu cenou mobilného telefónu (300 eur) a stanovením sumy 100 eur po zohľadnení doby viazanosti, na ktorú sa odporca zmluvne zaviazal mať aktivovaný účastnícky paušál a využívať služby navrhovateľa.

Odvolací súd z uvedených dôvodov po preskúmaní veci rozsudok prvostupňového súdu v odvolaní napadnutej časti a v súvisiacom výroku o trovách konania podľa ustanovenia § 219 ods. 1 a 2 O.s.p. ako vecne správny potvrdil.

O trovách odvolacieho konania krajský súd rozhodol podľa ustanovenia § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení a ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. Navrhovateľ si v súlade s ustanovením § 151 ods. 1 O.s.p. trovy odvolacieho konania riadne uplatnil a vyčísil. Odvolací súd navrhovateľovi, ako v odvolacom konaní úspešnému účastníkovi, priznal náhradu trov odvolacieho konania, spočívajúcich v trovách právneho zastúpenia a to za jeden úkon právnej služby podľa § 13a ods. 1 písm. c/ Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb - písomné podanie na súd - vyjadrenie k odvolaniu vo výške 51,45 eur a tomuto úkonu zodpovedajúci režijný paušál 7,63 eur (§ 16 ods. 3 vyhlášky), spolu 59,08 eur a 20% sadzby DPH, spolu v sume 70,90 eur, ktorú je odporca

povinný nahradiť navrhovateľovi na účet jeho právneho zástupcu špecifikovaný vo výrokovej časti tohto rozsudku a to v lehote do troch dní odo dňa doručenia tohto rozsudku.
Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Banskej Bystrici pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.